

1500320-39.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2039370/2021 - DEL.POL.SUZANO, 16162088 - DEL.POL.SUZANO, 593/21/309 - DEL.POL.SUZANO, 2039370 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTIAN LUPETI ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500320-39.2021.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500320-39.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2039370/2021 - DEL.POL.SUZANO, 16162088 - DEL.POL.SUZANO, 593/21/309 - DEL.POL.SUZANO, 2039370 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTIAN LUPETI LUCIANO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS

Vistos.

Cristian Lupeti Luciano, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Narra a denúncia que no dia 10 de fevereiro de 2021, por volta das 10h30, na Rua João Batista Gava nº 1, Jd. Cacique, nesta cidade e comarca de Suzano, o Réu trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 26 (vinte e seis) porções de maconha (Cannabis Sativa L), pesando aproximadamente 77,91g; 55 (cinquenta e cinco) porções de cocaína, pesando aproximadamente 47,08g, 121 (cento e vinte e um) porções de crack (subproduto da cocaína), pesando aproximadamente 23,32g; fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Laudo de exame pericial de constatação das drogas às fls. 30/33.

Certidão de antecedentes criminais do Réu às fls. 41/42.

Laudo de exame pericial químico-toxicológico definitivo às fls. 89/91.

Laudo de exame pericial de local às fls. 102/105.

O Ministério Público aditou a denúncia à fl. 109, para incluir a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, Lei nº 11.343/06.

Laudo de exame pericial de objeto às fls. 117/120.

Regularmente citado e notificado (fl. 111), o Réu apresentou defesa prévia à fl. 140/143.

A denúncia foi recebida às fls. 144/145, em 26 de outubro de 2021.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas Caio Cesar Ewert de Campos e Fabio Luiz Ribeiro de Lima. Regularmente intimado (fls. 175/176), o Réu não compareceu ao ato, razão pela qual foi decretada a sua revelia (fl. 178). Encerrada a instrução, foram apresentadas alegações finais por memoriais escritos pelo Ministério Público e pela Defesa, às fls. 183/186 e 189/192.

É o relatório. Fundamento e decido.

Não há preliminares a serem dirimidas.

No mérito, a presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls.

05/07, pelas fotografias de fls. 18/19, e laudos prévios e definitivos da droga de fls. 30/33 e fls. 89/91, respectivamente.

A autoria do delito foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 04) e demais provas produzidas em juízo.

Em audiência de instrução, a testemunha Caio Cesar Ewert de Campos, investigador de polícia, narrou que, em verificação à notícia anônima de tráfico de entorpecentes no local dos fatos, avistaram um indivíduo na proximidade, em posse de uma bolsa, o que chamou a atenção dos policiais. Por essas razões, resolveram abordá-lo. Em revista pessoal ao suspeito, encontraram entorpecentes e dinheiro em notas trocadas. No momento da abordagem, o acusado estava sozinho em uma esquina, não havia outras pessoas por perto. O local é bem próximo a uma escola, mas não sabe dizer se havia aulas no local no dia dos fatos.

No mesmo sentido, a testemunha Fabio Luiz Ribeiro de Lima, investigador de polícia, relatou que, em verificação à denúncia anônima a local de tráfico de entorpecentes, visualizaram o Réu, que tinha pochete na mão, o que chamou a atenção dos agentes públicos. Em revista pessoal, encontraram entorpecentes diversos no interior da bolsa e dinheiro. O acusado estava sozinho no local. Os valores apreendidos também estavam dentro da bolsa e se encontravam em notas trocadas. O Réu não informou quem lhe entregou as drogas. Havia uma escola próxima ao local, mas não se lembra se havia aulas no dia.

As provas colhidas sob a égide do princípio constitucional do contraditório fundamentam o decreto condenatório, não havendo de se falar em dúvida ou insuficiência aptas a beneficiar o acusado.

Com efeito, os depoimentos dos policiais civis que participaram das diligências, na qualidade de agentes públicos, fornecem embasamento suficiente para respaldar o pedido de condenação, tendo em vista a segurança e a coerência com que foram prestados, sendo certo que não se deve desconsiderar o teor de seus relatos apenas em razão de sua condição funcional.

Nesse sentido, é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo” STJ - HC 177980/BA rel. Min. Jorge Mussi J. 28/06/2011, e “Ainda que a condenação tivesse sido amparada apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório” (STJ - HC 30776 / RJ rel. Min. Laurita Vaz DJ 08.03.2004 p. 304).

No mesmo teor, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIAS DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações” STF HC 87662/PE rel. Min. Carlos Britto - J. 05/09/2006.

Em outras palavras, o depoimento dos agentes públicos só deve ser visto com reservas quando verificar-se a existência de interesse, como, por exemplo, para justificar eventual abuso de sua parte. No caso dos autos, não se vislumbra tal hipótese, tanto que as testemunhas sequer foram contraditadas, prestando depoimentos harmônicos e coesos.

Ademais, os policiais civis abordaram o Réu em razão de fundada suspeita – haja vista que o acusado se encontrava em local conhecido pela ocorrência de tráfico de entorpecentes, o qual foi objeto de denúncias anônimas, trazendo consigo pequena bolsa –, estando a sua atuação dentro dos estritos limites legais e constitucionais de suas funções, inexistindo nos autos provas que permitam inferir motivos para falsa incriminação, ou, ainda, quaisquer outros elementos que mitiguem os seus relatos em juízo.

Destaca-se, ainda, que não foram trazidos motivos idôneos para que fosse realizada eventual criminalização infundada pelas testemunhas, sendo certo que os policiais civis, na qualidade de agentes públicos, possuem atuação dotada de presunção de legitimidade e veracidade, o que não foi infirmado nos presentes autos.

Por outro lado, em delegacia, o Réu fez uso de seu direito constitucional ao silêncio, ao passo que, em sede judicial, não compareceu à audiência.

Por todo exposto, inexistem provas nos autos capazes de mitigar os relatos das testemunhas, as quais foram uníssonas em apontar que o Réu se encontrava na posse direta de entorpecentes variados, no interior de pochete.

No que tange à caracterização do tráfico, as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas confirmam sua destinação, porquanto pulverizadas em pequenas porções (fotografia de fl. 18) e de natureza diversificada (consoante laudo de constatação de fls. 30/33), em invólucros voltados à venda ou ao fornecimento a terceiros, em local que, segundo as testemunhas, é conhecido pelo tráfico.

No mais, a dinâmica dos fatos – consubstanciada na posse, pelo Réu, de pochete com drogas e de dinheiro em notas trocadas, em local previamente denunciado como sendo ponto de venda de entorpecentes – não permite a desclassificação para o delito de porte para consumo próprio (art. 28, Lei nº 11.343/06).

Logo, inviável a desclassificação para porte para consumo próprio, ante as circunstâncias de tempo, modo e espaço, bem como pela ausência de alegação do acusado neste sentido.

Sendo assim, diante do acervo probatório produzido nos autos e inexistindo causas de exclusão da tipicidade, licitude e culpabilidade, a procedência da ação penal é medida de rigor.

Passo, então, à dosimetria da pena, atendendo às diretrizes do art. 59, do Código Penal e art. 42, Lei nº 11.343/06.

Em primeira fase, a pena-base deverá ser fixada no mínimo legal, em razão da inexistência de provas nos autos que permitam inferir circunstâncias judiciais desfavoráveis. Destaco que a quantidade da droga (229,42g brutos – fl. 31) e a sua natureza não representam periculosidade à saúde pública para além da já considerada na tipicidade comum do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Logo, estabeleço a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase, não incide ao caso agravantes nem atenuantes.

Em terceira fase, viável a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, haja vista o preenchimento dos requisitos mínimos, em especial, a primariedade do agente

e a existência de bons antecedentes (certidão de fls. 41/42), bem como a ausência de provas de que se dedica exclusivamente às atividades de tráfico ou integraria organização criminosa.

Em que pese a existência de processo em curso em que se apura a participação do acusado delito da mesma espécie, verifico que o processo de nº 0010558-32.2018.8.26.0606. se encontra atualmente em curso, não havendo em seus autos sentença condenatória proferida.

Apesar de o § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 dispor que a reincidência, os maus antecedentes e a dedicação a atividades criminosas são empecilhos à incidência da causa de diminuição de pena – sendo possível a compreensão de que, diferentemente das duas primeiras, a dedicação ao tráfico não requer a existência de condenação com trânsito em julgado por fato anterior ao apurado nestes autos –, entendo ser necessário que haja, ao menos, sentença condenatória proferida em outro processo ou a verificação de situações evidentes, tais quais prisões em flagrante repetidas em curto espaço de tempo, de modo a impedir a incidência da minorante em questão. Neste sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça vem admitindo o afastamento do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas com a utilização de ações penais em curso, desde que haja sentença ou outros indicativos de que o acusado se dedica à atividade criminosa, vejamos:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEDICAÇÃO ATIVIDADE CRIMINOSA. UTILIZAÇÃO INQUÉRITOS E/OU AÇÕES PENAS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. I - O benefício legal previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 pressupõe o preenchimento pelo Réu de todos os requisitos cumulativamente, sendo eles: i) primariedade; ii) bons antecedentes; iii) não dedicação em atividade criminosa; iv) não integrar organização criminosa. II - O crime de tráfico de drogas deve ser analisado sempre com observância ao mandamento constitucional de criminalização previsto no artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal, uma vez que se trata de determinação do constituinte originário para maior reprimenda ao delito, atendendo, assim, ao princípio da vedação de proteção deficiente. III - Assim, é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica à atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 IV - In casu, o Tribunal de Justiça afastou a causa de diminuição de pena mencionada em virtude de o Réu ostentar condenação por tráfico de drogas não transitada em julgado, considerando que ele se dedica à atividade criminosa por não desempenhar atividade lícita, bem como porque 'assim que saiu da cadeia, voltou a praticar o mesmo delito'. Embargos de divergência providos para prevalecer o entendimento firmado no acórdão paradigma, restabelecendo o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça.”. (STJ; Embargos de Divergência em REsp nº 1.431.091/SP (2014/0015576-0), Min. Sebastião Reis Júnior; 6ª Turma).

Como nos autos do processo nº 0010558-32.2018.8.26.0606 não houve condenação do Réu nem em primeira instância, não é possível aferir, com algum grau de certeza, que este, de fato, se dedica à prática de atividades ilícitas. Outrossim, inexistem provas no sentido de que o acusado teria sido preso por outras condutas semelhantes.

Em outras palavras, inexistindo sequer condenação em primeiro grau de jurisdição, a presunção de não culpabilidade do acusado permanece hígida, não sendo mitigada pela simples existência de inquérito ou processo judicial em curso. Ademais, caso seja afastada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343 em razão da existência de ação penal em curso e o Réu venha a ser nessa inocentado ulteriormente, a fundamentação desta sentença terá se baseado em fato não reconhecido pelo próprio Poder Judiciário, o que importaria em contradição na prestação jurisdicional.

Logo, ante a ausência de ao menos sentença condenatória em tal processo – com vistas a mitigar a presunção de inocência do Réu quanto ao envolvimento em

associação criminosa -, inviável acolher o pedido de afastamento de causa minorante da pena nesta decisão, com base na existência de apenas uma ação penal em curso, cuja instrução sequer se encontra finalizada.

Sendo assim, reduzo a pena em 2/3, diante da pequena quantidade da droga e das circunstâncias da prisão do Réu, estabelecendo-a em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Com relação à causa de aumento contida no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, verifico que a prática da traficância ocorria a cerca de 30 (trinta) metros de campo de futebol (consoante laudo de local de fls. 102/105), por volta das 10h30, ou seja, nas imediações de recinto de "diversões de qualquer natureza". Do mesmo modo, trata-se de local próximo de unidade básica de saúde (fl. 105), a cerca de 100 (cem) metros. Por tais razões, aumento a pena em 2/6 (1/3), fixando-a em 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 221 (duzentos e vinte e um) dias-multa.

No que se refere à proximidade de instituição de ensino (cerca de 100m de distância), registro que o flagrante ocorreu durante a pandemia causada pela propagação do vírus Sars-Cov-2 (Covid-019), em fevereiro de 2021, não havendo provas nos autos que permitam inferir que, de fato, nesta época do ano, havia aulas na instituição de ensino em questão. Consoante se depreende de notícias jornalísticas veiculadas, as aulas totalmente presenciais retornaram somente no mês de agosto de 2021 e, nos meses anteriores, havia atividades espaçadas, de acordo com a capacidade de distanciamento de cada instituição de ensino, o que não permite a conclusão de que havia, de fato, risco efetivo aos alunos da escola estadual na data do crime. No mais, os policiais militares ouvidos em juízo não souberam informar se havia alunos no estabelecimento de ensino no dia e horário dos fatos. Assim, fixo a pena definitiva em 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 221 (duzentos e vinte e um) dias-multa.

Estabeleço o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à data do efetivo pagamento, à falta de elemento de convicção sobre a capacidade financeira do Réu que permita valoração diversa.

Fixo o regime aberto como inicial para cumprimento de pena, com fundamento no art. 33, §§ 2º e 3º, CP, uma vez que se trata de Réu tecnicamente primário, sem maus antecedentes.

Considerando que o acusado preenche os requisitos subjetivos e objetivos previstos no artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas penas restritivas de direito, consistentes (i) na prestação de serviços à comunidade e (ii) em prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, nos termos dos artigos 45, § 1º, 46, §§ 1º e 3º, ambos do Código Penal.

A prestação de serviços à comunidade ocorrerá pelo período fixado para cumprimento da pena corpórea, sendo facultado ao condenado cumprir em menor tempo, desde que não inferior à metade da pena privativa (art. 44, § 4º, CP), em entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções Criminais, observando-se, contudo, eventual suspensão em decorrência da fase do plano São Paulo relativo à pandemia Covid-19. A prestação pecuniária também será prestada a entidade indicada pelo Juízo da Execução.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para DECLARAR Cristian Lupeti Luciano como incurso nas penas do delito previsto no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 387, CPP, CONDENANDO-O ao cumprimento de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 221 (duzentos e vinte e um) dias-multa estabelecidos no valor mínimo legal, atualizados desde a prática delitiva, mediante a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos moldes acima fixados.

Tendo em vista que o Réu não foi encontrado na posse de dinheiro ou bens, deixo de determinar o seu perdimento, à luz do art. 63, I, Lei nº 11.343/06.

Em observância ao previsto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pelo delito, por se tratar de crime cuja vítima é a coletividade/saúde pública, não sendo possível

valorar, de forma individualizada, o prejuízo causado pela consumação do delito. Defiro ao Réu o direito de recorrer em liberdade (art. 387, § 1º, CPP) à luz do princípio da proporcionalidade e homogeneidade das penas, tendo em vista o quantum de pena aplicado, o seu respectivo regime inicial aberto e a substituição por restritivas de direito.

Expeça-se guia de cumprimento provisório de pena à vara de execuções criminais, se o caso. Após o trânsito em julgado: a) oficie-se ao instituto de identificação do Estado; b) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para fins de cumprimento do previsto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal; c) expeça-se guia de execução definitiva.

Custas na forma da lei (artigo 804, CPP).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Suzano, 21 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA